

الحمد لله

**أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:**

بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من الأستاذ... المحامي  
لدى التعقيب بتاريخ 2017/12/11 والمضمن تحت عدد 67،

نيابة عن: ن. ح.

**ضد:** شركة ك. في شخص ممثلها القانوني. نائبها... المحامي لدى  
التعقيب.

طعنا في القرار التعقيبي عدد 47343 الصادر بتاريخ 2017/06/20 القاضي  
بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا وتقض القرار المطعون فيه دون إحالة.

وعلى قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الصادر بتاريخ  
2017/11/22 بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة وتكليف المستشار المقرر  
بإعداد الدراسات اللازمة لتهيئة القضية للفصل.

وعلى تقرير الادعاء العام المؤرخ في 2018/02/27 الرامي مبدئيا إلى  
رفض مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا واحتياطيا قبوله شكلا وأصلا وإلغاء القرار  
المطعون فيه وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها.

وعلى مستندات الطعن المبلغ منها نظير للمعقب ضدها بتاريخ 2017/12/18  
بواسطة عدل التنفيذ ... برقيمه عدد 19278.

وعلى الرد على مستندات التعقيب المحررة من محامي المعقب ضدها المقدمة  
لكتابة المحكمة في 2018/01/17.

وعلى كافة أوراق القضية. وبعد المفاوضة طبق القانون، صرح بما يلي:

**من حيث الشكل:**

حيث استوفى المطلب جميع أوضاعه وصيغته القانونية وأضحى حريا بالقبول من هذه الناحية.

### من حيث الأصل:

حيث ينعي الطاعن على القرار التعقيبي المخدوش فيه الوقوع في الخطأ البين استنادا إلى أحكام الفصل 192 من م م م ت الذي نص على أنه: " تنظر الدوائر المجتمعة أيضا:

[...]

3-متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع."

ذلك أن القاضي السيدة ... سبق لها أن نظرت في القضية الابتدائية عدد 29922 الصادر الحكم فيها بتاريخ 2014/01/03 عن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها وكيل رئيس بها، كما شاركت في القضية التعقيبية عدد 47343 الصادرة عن محكمة التعقيب بتاريخ 2017/06/20 كمدع عام، وانتهى على ضوء ما سبق بيانه إلى طلب إبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها.

وحيث ردّا على مستندات التعقيب لاحظ الأستاذ ... نيابة عن المعقب ضدها أن وجود القاضية السيدة ... كان بوصفها مساعدة للسيد وكيل الدولة العام، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 187 من م م م ت الذي ينص على أنه بعد انتهاء الأجل المبين بالفصل 186 يحال ملف كل قضية على وكيل الدولة العام لتحرير ملحوظاته حول صحة الطعن من عدمه. وبالتالي فإن النيابة في النزاع تعد طرفا من ضمن الأطراف وأن رأيها لا يقيد المحكمة، لذا فهو يطلب تطبيق القانون بخصوص عريضة الطعن لمخالفتها للفصل 183 من م م م ت وفي الأصل الرفض أصلا.

### المحكمة

حيث إن الطعن بالتعقيب للخطأ البين هو وسيلة طعن استثنائية تخوّل للدوائر المجتمعة في حدود نطاق ضيق مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب متى توفرت حالة من الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من م م م ت وهي :

أولا: إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.

ثانيا: إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيّر غير منطبق.

ثالثا: إذا شارك في القرار ممن سبق منه النظر في الموضوع.

وحيث تأسس المطلب في قضية الحال على الصورة الثالثة، أي مشاركة أحد أعضاء الهيئة في الحكم الابتدائي ثم في القرار التعقيبي كمدع عام.

وحيث انحصر الإشكال القانوني تبعاً لذلك في معرفة إن كان المدعي العمومي الذي صدر القرار التعقيبي المطعون فيه بحضوره وضُمّن اسمه فيه، حال أنه سبق له المشاركة في إصدار الحكم الابتدائي، يُعدّ سبقاً منه في النظر في الموضوع تنضوي ضمن صورة الخطأ البين المنصوص عليها بالحالة عدد 3 من الفصل المشار إليه أعلاه؟

وحيث استقرّ فقه قضاء الدوائر المجتمعة على التأكيد أنه ولئن لم يعرف المشرع الخطأ البين كسبب يبرّر الطعن بالتعقيب كما لم يحدّد مفهوماً لعبارة "سبق منه النظر في الموضوع"، فإنه مما لا جدال فيه أن إرساء هذه القاعدة يأتي في إطار تكريس مبدأ أساسي من المبادئ العامة المنظمة لمرافق العدالة المنصوص عليه بالفصل 103 من الدستور، والمتمثل في مبدأ حياد القاضي. "فأساس رغبة المشرع من خلال عدم جواز إبداء الرأي فيما سبق إبداء الرأي فيه إنما هو استبقاء مظهر الحياد لدى القاضي عند البت في النزاع". (قرار تعقيبي مدني عدد 257 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 22 فيفري 2007).

وحيث يُفضي هذا المبدأ إلى عدم صلاحية القاضي للنظر في قضية معينة لوجود صلة سابقة بينه والدعوى المعروضة عليه تبعاً لسبق إبداء رأيه فيها، أي وجود فكرة مسبقة لديه عن الدعوى يحتمل أن يميل للأخذ بها، وهو ما يُخلّ بموضوعيته وحياده، ويتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، ولا يجد نفسه مدفوعاً إلى التشبث برأيه الذي أبداه مخالفاً بذلك مجرى العدالة.

وحيث إن سبق النظر في الموضوع هي قاعدة إجرائية، وبهذا المعنى فهي لا تفيد الإطلاق وإنما تأوّل تأويلاً ضيقاً، ويبقى تقديرها من جهة أولى رهين توفر شروط محددة، ومن جهة ثانية يُنظر فيها حالة بحالة وفقاً لمعطيات وظروف كل قضية، ولا يكفي بالتالي مجرد الظاهر منع الجمع المتتالي للوظائف القضائية.

وحيث استقرّ فقه قضاء الدوائر المجتمعة على ضرورة توفر ثلاثة شروط لقيام حالة سبق النظر في الموضوع: (قرار عدد 345 بتاريخ 2018/04/26 وعدد 350/2015 بتاريخ 2017/03/02).

1- أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأياً في الدعوى المعروضة عليه.

2- أن يكون نظره في نفس المسار القضائي للقضية.

3- أن يتعلق الأمر بنفس موضوع القضية سواء بالنسبة للوقائع أو السند القانوني أو الطلبات .

وبتنزيل هذه الشروط على ملف قضية الحال يتبين أن المدعي العمومي قد سبق له معرفة نفس موضوع القضية ضمن ذات المسار القضائي لَمَّا كان عضواً بالهيئة الحكومية التي أصدرت الحكم الابتدائي، ثم شارك في القرار التعقيبي وضمّن إسمه بلائحته رغم سبق النظر منه في نفس موضوع القضية.

وحيث إن المشاركة ممن سبق له النظر في الموضوع التي تعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت، إنما هو مشاركة نفس القاضي وإبداء رأيه في مسألة قانونية أو واقعة قانونية لها تأثير على وجه الفصل في النزاع المعروض ثانية، وذلك إما بالمساهمة مباشرة في الحكم فيه مرة أخرى، أو المساهمة أيضاً في صياغة الرأي القانوني وتكوين الحل الذي انتهت إليه المحكمة. ذلك أن أساس رغبة المشرع من خلال عدم جواز إبداء الرأي فيما سبق إبداء الرأي فيه هو صون مبدأ الحياد الموضوعي للقاضي واستبقاء مظهره لديه عند البت في النزاع خشية أن يؤثر رأيه السابق على رأيه اللاحق.

وحيث إن حضور المدعي العمومي في قضية الحال وتمسكه بالطلبات الكتابية المقدمة تطبيقاً لأحكام الفصل 187 من م م م ت، يُعتبر مشاركة في القرار ممن سبق منه النظر في الموضوع لما له من تأثير على وجه الفصل في القضية.

وحيث بتضمين المدعي العمومي لرأيه بالطلبات الكتابية والتمسك بها جلسة، يكون قد ساهم في تكوين الحل المقضي به في الملف، بما من شأنه أن يُولد لدى المتقاضى إحساساً مبرراً بعدم الأمان من ضمان الحياد الموضوعي للمحكمة ويمثل تبعاً لذلك خطأ بينا لتحقيق مقصد المشرع من القاعدة على معنى الفصل 192 من م م م ت في فقرته الثالثة.

وحيث يتعين لذلك إبطال القرار التعقيبي المطعون فيه عدد 47343 الصادر بتاريخ 20/06/2017، وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للإذن بإعادة نشرها أمام إحدى الدوائر التعقيبية، وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

### ولهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب الخطأ البين شكلاً وأصلاً وإبطال القرار التعقيبي عدد 47343 الصادر بتاريخ 20/06/2017 وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للإذن بإعادة نشرها أمام إحدى الدوائر التعقيبية وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

وصدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة بحجرة الشورى يوم الخميس 14 فيفري 2019 برئاسة السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

### وعضوية رؤساء الدوائر السادة:

نازك كادة، البشير المطوي، كمال مصطفى العلاني، نعيمة رحيم، المنصف الكشو، كوثر السعدي، لطيفة البغدادي، سارة العياري، ماجدة بن غربية، ماهر كريشان، منيرة النحالي، محمد عماد بن عبد الجليل، سلوى النهدي، جلال الدين بوكتيف، وسيلة التليلي، روضة أوبيش، جمال المستيري، آسيا العياري، حياة البصلي، عبلة بن شعبان، جلييلة نصر الله، حاتم بن عجال، المنجي شلغوم، عادل الاندلسي، رياض الامام، رياض الموحلي، لمياء الحمامي، زهرة السلامي، محمد كمال وديك.

### والمستشارين السادة:

ماهر كنو، عبد الباسط الخالدي، أنور المليح، فاخر بركات، زينب لغلوغ، رجاء بوسمة، حاتم بن جماعة، بديع بن عباس، عفاف عالشيخ، راضية المنتصر، نجيب العرعوري، وريدة الغربي، مفيدة المداغي، سامية القطاري، رؤوف ملكي، سميرة الحويوي، ريم منية البحري، عبد الرزاق الباهوري، منير وردليتو، هنده العلاقي، أحمد الغالي، صالحة النحالي، محمد الورهاني، ابراهيم الغرياني، أمل العرفاوي، فاتن خير الله، نجلاء المصمودي، عادل الأخضر، بسمة بودن، هالة البجار، سهام الشاهد، بسمة العبساوي.

وبمحضر السيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة عفاف الحاجي.

وحرر في تاريخه